

1500624-14.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... traziam consigo para fins de tráfico, 78 (setenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido total de 34,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 176,75 em dinheiro.

Consta, ainda, que os réus se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500624-14.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500624-14.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2053616/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23226343 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 653/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2053616/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE MAYARA FROIS CHERMONT e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público, em face de Aline Mayara Frois Chermont, Ailson Monteiro Chermont (que também utiliza o nome Ailson Frois Chermont) e Flavio da Silva Tavares Oliveira, devidamente qualificados aos autos, como incurso nas penas dos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 15h05min, na Rua Montese, altura do numeral 228, Vila Padre Manoel da Nóbrega, nesta cidade e

comarca de Campinas/SP, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Silva Padre, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo para fins de tráfico, 78 (setenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido total de 34,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 176,75 em dinheiro.

Consta, ainda, que os réus se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante (págs. 08/10); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 18/20); auto de exibição e apreensão (págs. 21/22); laudo de constatação preliminar (págs. 24/26) e laudo definitivo (págs. 192/194).

Por decisão datada de 22 de março de 2022 (págs. 227/228), foi determinada a notificação dos acusados, sendo apresentada defesa preliminar (págs. 245/246). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (págs. 247/249) e os réus devidamente citados, ocasião em que designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, os acusados foram interrogados.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa do acusado Flávio pleiteou pela absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, regime diverso do fechado, direito de recorrer em liberdade e detração penal.

A defesa dos acusados Ailson e Aline, requereu a absolvição; subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da menoridade penal, aplicação do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

Vejamos.

A testemunha Vinicius Antônio do Nascimento, policial militar, em sede administrativa, narrou que estava em patrulhamento de rotina pela Rua Montezi, 228, Bairro Castelo Branco, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou três pessoas, sendo que dois homens estavam juntos e uma mulher estava cerca de 05 (cinco) metros deles. Os indivíduos gritaram "pastel" e saíram correndo em sentidos opostos. A acusada jogou uma sacola na via pública que continha 03 kits, cada qual com 26 saquinhos plásticos embalados à vácuo com substância de cor branca aparentando ser cocaína. Realizada revista pessoal por uma policial feminina, foi encontrada com a acusada a quantia de R\$ 176,75 reais em cédulas diversas. Os acusados foram abordados e traziam, cada um, a quantia de R\$ 14,00 reais. Eles admitiram que estavam na função de "olheiros" e ganhavam a quantia de R\$ 150,00 reais. Por fim, aduziu que o local fica próximo a uma praça, bem como a cerca de 100 metros é dotado de uma escola e uma creche.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento, momento em que os acusados, ao avistarem a viatura, começaram a gritar "pastel" e saíram correndo. Realizada a abordagem, a ré Aline jogou uma sacola ao solo. Os réus traziam dinheiro e na sacola dispensada pela acusada havia cocaína. Na posse da ré, foi possível localizar, ainda, uma certa quantia em dinheiro. Os réus disseram que trabalhavam como "olheiros".

A testemunha Felipe Rodrigues da Silva, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas. Nesse momento, visualizaram três indivíduos que, ao avistarem a viatura, gritaram "pastel" e saíram correndo. A acusada Aline jogou uma sacola ao chão. Os réus confirmaram que estavam na prática de tráfico de drogas e atuavam como

"olheiros".

A testemunha José Ricardo Pereira Agape, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e ao adentrarem a Rua Montezi, observaram que os acusados estavam reunidos. Ao visualizarem a viatura, os acusados gritaram "pastel" e tentaram correr. A acusada jogou uma sacola ao chão que continha cocaína. A ré ainda trazia uma certa quantia em dinheiro. Por fim, aduziu que Aline vendia as drogas, ao passo que Ailson e Flávio atuavam como "olheiros" e ganhavam R\$ 120,00 reais.

A testemunha Leda Nicole Teixeira Matos Doubovets, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega de farda.

Em juízo, disse que foi chamada para realizar busca pessoal na acusada. No bolso da ré havia um pacote contendo dinheiro. Informou, por fim, que a ré disse que atuava na função de "olheiro".

A ré Aline Mayara Frois Chermont, em sede administrativa, disse que estava na campana quando escutou gritos, saiu correndo e achou o dinheiro. Aduziu que ganhava R\$ 150,00 reais por dia, mas era segunda vez que tinha ido ao local.

Em juízo, negou o crime. Disse que seu marido, Ailson, estava traficando no local e, em dado momento, ouviram um grito, motivo pelo qual saiu correndo. Disse que não trazia droga e não jogou nenhuma sacola ao solo. Aduziu, por fim, que encontrou o dinheiro no chão.

O réu Ailson Monteiro Chermont (que também utiliza o nome Ailson Frois Chermont), em sede administrativa, negou o crime. Que já foi preso por tráfico anteriormente. Em juízo, disse que atuava como "olheiro", mas Aline não estava na prática do tráfico de drogas.

O réu Flávio da Silva Tavares Oliveira, em sede administrativa, disse que é usuário de crack. Que estava precisando de dinheiro para cortar o cabelo e comprar uma mochila nova. Que no dia dos fatos estava atuando como "olheiro" e receberia R\$ 50,00 a R\$ 100,00 reais. Por fim, aduziu que já foi preso por crime contra o patrimônio.

Em juízo, disse que é morador de rua e foi chamado para atuar como "olheiro". Aduziu que no dia dos fatos a acusada Aline trazia a sacola contendo drogas conforme informado pelos policiais.

Para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

O conjunto probatório permite inferir que os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo para fins de tráfico, 78 (setenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido total de 34,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 176,75 em dinheiro.

Importante salientar que a conduta dos acusados se amolda perfeitamente ao tipo penal supracitado.

Para caracterizar o delito, basta que um dos verbos descritos no tipo se concretize, não sendo necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto que se trata de crime de perigo abstrato.

Oportunamente, cumpre destacar que os policiais militares reconheceram os réus com sendo os autores do delito.

Ouvidos sob o crivo do contraditório foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão dos réus e na apreensão de todo o material. Destarte, inexistente qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos

oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266) Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54) São eles agentes do Estado, incumbidos a reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Ademais, é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não bastasse, os réus Ailson e Flávio confessaram a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que os acusados, pessoas maiores, capazes e no gozo de suas faculdades mentais, estavam assistidos por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Por sua vez, a negativa da ré Aline em juízo restou isolada diante de uma análise minuciosa dos fatos.

O acusado Flávio, em juízo, confirmou que a acusada trazia consigo a sacola contendo drogas, o que vai em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Ademais, o modo do acondicionamento da droga, a divisão de tarefas mostram que elas se destinavam ao comércio.

As substâncias entorpecentes descritas na peça inaugural foram confirmadas pelo laudo de constatação preliminar e pelo laudo pericial definitivo, atestando seus efeitos e sua periculosidade, sendo detectadas, de fato, a presença de cocaína. As circunstâncias do flagrante, a confissão em juízo dos acusados Ailson e Flávio e, ainda, o valor em dinheiro apreendido proveniente do comércio espúrio, impossibilitam a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal.

É certo que, se é fato que o tráfico de drogas ilícitas banalizou-se, a ponto de propiciar a qualquer pessoa, mesmo que de renda mensal mínima a possibilidade de ganhar dinheiro com o tráfico, não é em razão disso que a conduta típica e antijurídica venha a ser menos perniciosa para a sociedade, posto que, como é cediço, o crime de tráfico, cujo bem jurídico é a saúde pública, dá causa, inegavelmente, a inúmeros outros ilícitos penais que são perpetrados em razão das drogas ou para propiciar a aquisição delas.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Ainda, restou caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei

11.343/06, uma vez que, no caso em apreço, a prática do delito se deu nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Silva Padre. Embora a referida causa de aumento não conste na capitulação da denúncia, não há necessidade de aditamento. Conforme é sabido, os acusados se defendem do fato descrito na exordial acusatória, não da capitulação dada pelo Ministério Público. Para o delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06:

Em relação ao crime de associação ao tráfico, dispõe o artigo 35, da Lei n.

11.343/06: "Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Conforme se vislumbra, para a configuração do delito, exige-se o ânimo associativo, ou seja, verificação de que a associação se dá de modo estável e com um mínimo de organização e divisão de tarefas.

Na hipótese, não se comprovou que os acusados tenham se associado, previamente, de maneira duradoura e com um mínimo de organização e divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas. Ao contrário, pelo que se depreende dos autos e oitiva dos policiais militares, restou claro que houve encontro ocasional de vontades, gerando auxílio mútuo para a prática do tráfico de drogas.

Não há notícias de que tenha sido realizada outra diligência para confirmação de que essa atuação conjunta dos réus para o comércio ilícito se repetia com frequência e estabilidade.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06.

REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada para fins de configuração do crime descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/76. Absolvição que não demandou o reexame de provas, mas apenas sua reavaliação. (...) 4. Agravo regimental desprovido" (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 507.278/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/08/2014).

Assim, de rigor a absolvição dos acusados em relação ao delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Para o réu Ailson Monteiro Chermont (que também utiliza o nome Ailson Frois Chermont).

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes (proc. 0013512-14.2014.8.26.0114 pág. 77) e, ainda, levando-se em consideração que estava em prisão domiciliar quando praticou o crime (pág. 77)

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência específica (proc. 0000779-33.2018.8.26.0548 - pág. 76), majoro a pena em 1/3 (um terço). Em seguida, verificada a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Tendo em vista que a reincidência específica demonstra profissionalização na conduta criminosa, deixo de compensá-la com a atenuante da confissão. Nesse sentido: "A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a reincidência genérica" (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski.)

Na terceira fase, deixo de conceder o benefício ante a reincidência do acusado. Ressalto que passo a reconhecer a reincidência e a exclusão do benefício contido no artigo 33, parágrafo 4o da Lei, em consonância com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal

de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. 5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do paciente, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, "a", do CP. Precedentes. (HC 391152 / SP, HABEAS CORPUS 2017/0049230-0)

Por fim, caracterizado o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Para o réu Flávio da Silva Tavares Oliveira:

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes (proc. 0080773-52.2018.8.26.0050 – pág. 83) e, ainda, levando-se em consideração que estava em regime aberto quando praticou o crime (pág. 83)

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (proc. 0064649-91.2018.8.26.0050 – págs. 83/84), com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, deixo de conceder o benefício ante a reincidência do acusado. Ressalto que passo a reconhecer a reincidência e a exclusão do benefício contido no artigo 33, parágrafo 4o da Lei, em consonância com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. 5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do paciente, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, "a", do CP. Precedentes. (HC 391152 / SP, HABEAS CORPUS 2017/0049230-0)

Por fim, caracterizado o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Para a ré Aline Mayara Frois Chermont.

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis à ré.

Na segunda fase, verificada a atenuante da confissão extrajudicial, mas tendo em vista que a pena não pode ir aquém do mínimo legal, matenho-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, para a redução da pena, é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, comprove que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Contudo, o §4º do artigo 33, tem sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais de indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo.

Deve o julgador, neste caso, sopesar a quantidade de droga, variedades destas, bem como a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução.

Em relação a ré, considerando os novos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e o quanto determinado pelo STJ, observo que a quantidade de droga não é expressiva de modo a inviabilizar o benefício em questão. Assim, sendo o caso de aplicação do benefício no percentual de 2/3 (dois terços), resultando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre a possibilidade de utilizar a quantidade e diversidade de drogas como critério para diminuição da pena já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder da paciente justificam a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, no piso mínimo (um sexto). 2. As instâncias inferiores decidiram em consonância com a jurisprudência desta e. Corte Superior, não caracterizada a coação ilegal descrita na inicial. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 150407)

Por sua vez, oportuno ressaltar que não é inconstitucional a referida sanção pecuniária, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei de Drogas - Redutor de pena já beneficemente aplicado, em fração intermediária - Penas e regime prisional fixados com critério - Manutenção da pena de multa imposta, afastada a alegação de inconstitucionalidade - Negado provimento ao recurso. (TJ/SP - Apelação n.º 0014590-34.2014.8.26.0602/ SP, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, julgado em 30/07/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, publicado em 02/08/2015).

Por fim, caracterizado o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de:

1)- CONDENAR o acusado AILSON MONTEIRO CHERMONT (que também utiliza o nome Ailson Frois Chermont) ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06; e ABSOLVER o acusado, da infração contida no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2)- CONDENAR o acusado FLÁVIO DA SILVA TAVARES OLIVEIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06; e ABSOLVER o acusado, da infração contida no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3)- CONDENAR a acusada ALINE MAYARA FROIS CHERMONT ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06; e ABSOLVER a acusada, da infração contida no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino regime semiaberto para início do cumprimento de pena da acusada Aline, adotando como posicionamento a fundamentação exarada no V.Acórdão 2018.000245841, sendo relator o sempre culto Desembargador Nelson Fonseca Júnior;"... a teor a despeito da extensão das penas corporais aplicadas, não é caso de se manter o regime inicial aberto; quer em razão da gravidade do delito e da natureza de um dos entorpecentes apreendidos, quer em razão de o regime inicial aberto não se mostrar suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo réu (cf.

artigo 33, § 3º, do Código Penal), além de não garantir o cumprimento das penas substitutivas impostas."

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e a frequência a curso ou tratamento pelo período de cumprimento de pena em locais a serem indicados pelo Juízo da Execução.

A ré poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu solta durante a instrução. Para os réus Flávio e Ailson, determino o regime fechado para início de cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a gravidade do delito cometido, bem como a reincidência, sendo, portanto, incabível a aplicação de regime mais brando.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, visto que permaneceram presos durante a instrução e persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Oportuno ressaltar que os réus possuem maus antecedentes, são reincidentes e delinquiram em regime aberto o que mostra que em liberdade, voltarão a delinquir.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito cometido, circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra os réus, bem como a reincidência.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA